

<제08장 청구의 병합과 소의 변경.제01절 관련청구소송의 병합·이송>

[기출][2021-1-2]무효확인소송 계속 중 동일한 처분에 대한 취소소송 추가 병합의 적법 여부

《[문제1] 증기계를 생산하는 제조회사에 근무하는 甲은 골절 등의 업무상 사고로 인하여 상해를 입었음을 이유로 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등의 지급결정을 받았다. 그 후 근로복지공단은 甲이 실제 상해를 입지 않았음에도 허위로 지급신청서를 작성하여 급여지급결정을 받은 사실을 들어 甲에 대한 급여지급결정을 취소하였고, 甲은 급여지급결정의 취소처분을 2021. 1. 7. 직접 수령하였다. 이와 함께 근로복지공단은 이미 甲에게 지급된 급여액에 해당하는 금액을 부당이득으로 징수하였다. 한편, 甲은 위 급여지급결정 취소처분이 위법함을 이유로 2021. 5. 7. 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 상호 관련성이 없는 별개의 문항임) (50점)

(물음2) 위 무효확인소송의 계속 중 甲은 추가적으로 급여지급결정 취소처분의 취소를 구하는 소를 병합하여 제기할 수 있는가? (20점)

「국가배상법 제2조(배상책임)」

❶ 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 '공무원'이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다. 다만, 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무 집행과 관련하여 전사(戰死)·순직(殉職)하거나 공상(公傷)을 입은 경우에 본인이나 그 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 「민법」에 따른 손해배상을 청구할 수 없다.》

<문제1의 물음2> 무효확인소송 계속 중 동일한 처분에 대한 취소소송 추가 병합의 적법 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 근로복지공단의 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송을 제기한 후, 동일한 처분에 대한 취소소송을 추가로 병합하여 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인소송 계속 중 처분의 취소를 구하는 청구를 추가하는 것이 소의 변경 또는 청구의 병합으로서 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송과 취소소송의 병합 가능성 및 그 요건을 설명한다.

II. 무효확인소송과 취소소송의 병합에 관한 법리

1. 관련 청구소송 병합의 의의 및 요건

(1) 의의

- 「행정소송법 제10조 제1항」은 처분등의 취소청구소송에 관련청구소송을 병합하여 제기할 수 있도록 규정하고 있으며, 「동법 제38조 제1항」은 이를 무효등확인소송에도 준용한다. 이는 분쟁의 일회적 해결을 도모하고 판결의 모순·저축을 방지하기 위함이다.

(2) 요건

- 소의 병합이 인정되기 위해서는 주된 청구와 병합되는 청구 사이에 관련성이 존재해야 하며, 본안 심리를 담당하는 수소법원이 두 소송에 대해 모두 관할권을 가져야 한다. 동일한 처분의 무효확인 청구와 취소 청구는 전형적인 관련청구소송에 해당한다.

2. 병합의 형태적 한계

(1) 단순 병합 및 선택적 병합의 불허

- 동일한 처분에 대해 무효를 구하는 청구와 취소를 구하는 청구는 처분의 하자의 정도를 다르게 평가하는 것으로서 서로 양립할 수 없다. 따라서 법원이 두 청구를 모두 인용하거나 그중 하나를 임의로 선택하여 인용할 수 있는 단순 병합이나 선택적 병합의 형태는 허용되지 않는다.

(2) 주위적·예비적 병합의 허용

- 「판례」는 무효확인청구와 취소청구는 서로 양립할 수 없는 관계이므로 주위적·예비적 청구 형식으로만 병합이 가능하다고 본다. 사안의 경우 이미 제기된 무효확인소송을 주위적 청구로 삼고, 추가 병합하는 취소소송을 예비적 청구로 삼는 병합만이 적법하게 인정된다.

3. 병합된 취소소송의 제소기간 준수 여부

(1) 제소기간의 독립적 심사

- 추가적으로 병합되는 청구라 하더라도 제소기간과 같은 소송요건은 개별적·독립적으로 심사되어야 한다. 「행정소송법 제20조 제1항」에 따라 취소소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기되어야 하는 불변기간의 제한을 받는다.

(2) 소 제기 시점의 기준

- 예비적 청구로 병합되는 취소소송의 제소기간 준수 여부는 주위적 청구인 무효확인소송이 제기된 시점이 아니라, 예비적 청구인 취소소송이 실제로 추가 병합되어 법원에 제출된 시점을 기준으로 판단하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. 병합의 형태적 적합성 검토

(1) 병합의 가능성

- 甲이 이미 제기하여 진행 중인 급여지급결정 취소처분 무효확인소송에 동일한 처분의 취소소송을 병합하는 것은 「행정소송법 제10조 및 제38조 제1항」에 따라 객관적 병합으로서 기본적으로 허용된다.

(2) 예비적 병합의 의무화

- 다만, 두 청구는 실제법상 하자의 정도를 달리하는 양립 불가능한 관계이므로, 甲은 기존의 무효확인소송을 주위적 청구로 유지하고 새로 추가하는 취소소송을 예비적 청구로 삼는 주위적·예비적 병합의 형태로 소를 제기하여야 한다.

2. 병합된 취소소송의 제소기간 도과 여부 판단

(1) 제소기간의 만료 시점

- 사안에서 甲은 급여지급결정 취소처분서를 2021. 1. 7. 수령하여 처분이 있음을 직접 알게 되었다. 따라서 「행정소송법 제20조 제1항」에 따른 취소소송의 제소기간은 초일불산입 원칙에 따라 2021. 1. 8.부터 기산하며, 90일이 경과하는 날인 2021. 4. 7.에 만료된다.

(2) 병합 제기 시점과 적법성

- 甲이 최초 무효확인소송을 제기한 시점은 2021. 5. 7.로서, 이 시점에 이미 취소소송의 제소기간인 2021. 4. 7.을 경과하였다. 취소소송의 추가 병합은 이보다 더 늦은 소송 계속 중에 행해지므로, 예비적으로 병합된 취소소송은 불변기간인 제소기간을 명백히 도과하여 제기된 소로서 소송요건을 결여하였다.

IV. 결론

- 사안에서 甲이 제기한 무효확인소송 계속 중 동일한 처분에 대한 취소소송을 예비적으로 병합하여 제기하는 것은 소의 병합 형식 자체로는 가능하다. 그러나 추가 병합되는 예비적 취소소송 역시 독립하여 제소기간을 준수하여야 하는바, 甲이 처분을 안 날인 2021. 1. 7.로부터 90일이 훨씬 경과한 시점에 소를 병합하였으므로 이는 제소기간 요건을 흠결하였다. 결론적으로 법원은 甲이 추가적으로 병합 제기한 취소청구에 대하여 제소기간 도과를 이유로 부적법 각하 판결을 내려야 한다.